

1500533-17.2022.8.26.0129

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE ALFREDO DE ANDRADE FILHO

Comarca: Casa Branca

Foro: Foro de Casa Branca

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... era "gente boa", mas o acusado estava no tráfico; em um quarto, foram encontradas mais porções de maconha, cocaína e uma balança de precisão. Esclareceu que o motorista do veículo sabia do tráfico e relatou que tinham buscado entorpecentes em Porto Ferreira. Foi apreendido em torno de R\$ 190,00 a R\$ 200,00 com o réu, em notas diversas. Esclareceu, ademais, que, durante o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Casa Branca

Foro de Casa Branca

2ª Vara

Praça Ministro Costa Manso, 78, Casa Branca-SP - cep 13700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500533-17.2022.8.26.0129 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500533-17.2022.8.26.0129

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2198167/2022 - DEL.POL.ITOBI, 26275657 - DEL.POL.ITOBI, 2198167 - DEL.POL.ITOBI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO PEDRO BARBOSA FILHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE ALFREDO DE ANDRADE FILHO

Vistos.

FRANCISCO PEDRO BARBOSA FILHO foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, porque, no dia 21 de julho de 2022, por volta de 16h30min, na Estrada Municipal, 2, rural, na cidade de Itobi, nesta Comarca de Casa Branca, trazia consigo e transportava, para fins de entrega a consumo de terceiros, sete porções de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", pesando cerca de 84,32g (oitenta e quatro gramas e trinta e dois decigramas), e duas porções de cocaína, pesando cerca de 7,20g (sete gramas e vinte decigramas), bem como nove eppendorfs de cocaína, pesando aproximadamente 17,40g (dezessete gramas e quarenta decigramas), substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Adotado o procedimento ordinário, a denúncia foi recebida (fls. 62/65) e o acusado foi regularmente citado (fl. 93) e apresentou resposta à acusação (fls. 101/104).

Recebida a denúncia no dia 04 de março de 2022 (fls. 101/102).

Em audiência de instrução, foram inquiridas testemunhas arroladas pelo Ministério Público e, ao final, o réu foi interrogado (fls. 172).

Encerrada a fase instrutória, abertos os debates orais, o Ministério Público postulou a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia, ao passo que a d. Defesa alega, preliminarmente, nulidade da busca pessoal e do ingresso na residência do réu; no mérito, requer absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a solicitação a desclassificação para o crime previsto no artigo 33, §3º da Lei 11.343/06; o reconhecimento do tráfico privilegiado; a fixação do regime aberto; e a substituição da pena privativa por restritiva de direitos.

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, cujo processo, em trâmite pelo rito ordinário, apura a materialidade e autoria do episódio criminoso narrado na denúncia.

Finda a instrução, por mais respeitáveis que possam ser os argumentos exculpatórios, temos que a pretensão punitiva é procedente.

Relativamente às nulidades alegadas pela d. Defesa, deixo para apreciá-las em conjunto com o mérito, já que, para se concluir pela ocorrência ou não da alegada conduta ilícita, faz-se necessária a análise aprofundada do conjunto probatório amealhado aos autos.

A materialidade foi comprovada pelos elementos informativos que instruem os autos, em especial, pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01 e seguintes), pelo boletim de ocorrência (fls. 8/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 30/31), pelos laudos periciais de fls. 158/171, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria é incontestável, conforme se comprovou pela prova oral.

As testemunhas arroladas pelo Ministério Público foram ouvidas sob o crivo do contraditório.

O Policial Militar Carlos Eduardo Emiliano relatou, em resumo, que, no dia dos fatos, observaram três indivíduos em uma praça, com características de que estavam utilizando drogas; ao lado, verificaram a existência de um veículo Uno branco, em relação ao qual havia denúncia de que era utilizado para trazer drogas para Itobi. Realizada a abordagem, com o acusado foram localizadas cocaína, maconha e a quantia de R\$ 90,00. O réu confessou que estava traficando e aguardando a chegada de uma pessoa que iria buscar droga na praça. Ato contínuo, realizaram busca no veículo, no qual encontraram mais cocaína e maconha. O acusado confessou que na sua casa tinha "mais coisas". Na residência, a mãe do réu os recepcionou e disse-lhes que tinha ciência do tráfico e que o réu não precisava disso, porque eram pessoas trabalhadoras. Realizada busca, em um guarda-roupa, foram achadas mais três porções de maconha, de tamanho razoável, ainda não fracionadas, e uma porção de cocaína a granel, também de tamanho razoável, alguns pinos de cocaína e uma balança de precisão. O acusado assumiu toda a droga, dizendo que toda droga que fosse localizada era dele. Os outros que estavam com o réu confirmaram que tinham ido com ele a Porto Ferreira buscar drogas. Não gravou a mãe do acusado autorizando o

ingresso na residência. Esclareceu que o motivo da abordagem se deu em razão de os indivíduos estarem aparentando o uso de entorpecentes na praça, praça sempre ocorre o uso de maconha; e que atitude suspeita consistiu no fato de aparentarem estar assustados.

O Policial Militar Vanil de Carvalho Júnior relatou, em resumo, que, no dia dos fatos, realizavam patrulhamento quando visualizaram três indivíduos sentados na praça; havia muitas denúncias de uso de entorpecentes e de tráfico de drogas; diante disso, decidiram fazer a abordagem. Com o acusado, foram encontrados um tubo de cocaína, um de maconha e um saquinho de cocaína. Em conversa com o réu, este assumiu que estava traficando e que estavam naquele local, esperando pessoa para entregar as substâncias entorpecentes. Relatou que havia várias denúncias relacionado a um Fiat Uno branco; o réu e as outras duas pessoas falaram que estavam com o veículo; realizada vistoria no automóvel, foram localizadas mais drogas; em seguida, proferiram voz de prisão em flagrante. Na delegacia, o réu relatou que tinha mais droga na casa dele. Diante disso, dirigiram-se à residência do réu, oportunidade em que com a franquia dele e de sua genitora, ingressam no imóvel; a mãe do réu disse que era "gente boa", mas o acusado estava no tráfico; em um quarto, foram encontradas mais porções de maconha, cocaína e uma balança de precisão. Esclareceu que o motorista do veículo sabia do tráfico e relatou que tinham buscado entorpecentes em Porto Ferreira. Foi apreendido em torno de R\$ 190,00 a R\$ 200,00 com o réu, em notas diversas. Esclareceu, ademais, que, durante o patrulhamento, visualizaram os três indivíduos na praça, praça na qual é comum uso de entorpecentes e tráfico de drogas; que, diante da atitude suspeita fizeram abordagem; que tinha denúncia, no sentido de que o veículo Fiat Uno era utilizado no tráfico de drogas em Itobi. Mencionou, ao final, que não efetuaram gravação do ingresso na residência, mas mãe do réu afirmou que era para entrar e tirar a droga e estava muito triste, porque não queria seu filho nesse caminho.

Ao final, o réu, sob a égide processual, foi interrogado. Em resumo, relatou que, no dia dos fatos, foi em Porto Ferreira para comprar drogas para consumir; na volta, deixou as drogas em casa, pegou três pinos e foi para Itobi ver sua mulher; pagou seu amigo para leva-lo em Itobi; estava aguardado sua mulher para ir no mercado, quando os policiais chegaram; os policiais falaram que iam levá-lo preso, mesmo "se tivesse sem nada"; em seguida, o delegado compareceu ao local, momento em que o policial afirmou que ele estava levando drogas para Itobi; negou para o delegado que estava traficando; que o primeiro delegado que prestou depoimento o agrediu e disse que ele era mentiroso e começou a xingá-lo, falando que ia levar ela, seu irmão e mãe presos; perguntaram se tinha mais droga em casa e falaram que não apresentasse as drogas ia levar seu irmão e sua mãe; diante disso, confirmou que estava traficando para livrar sua mãe; ato contínuo, na residência, ingressaram sem pedir permissão para entrar; sua mãe ficou em desespero, quando viu os policiais entrando na sua casa; no quarto, mostrou as drogas que tinha para consumo. Esclareceu que a balança apreendida era de sua mulher, pesar bolo. Afirmou que não deixaram ler os documentos e "só deram" para assinar. As drogas eram para seu consumo. Disse que os outros dois que estavam em sua companhia iriam suas drogas com ele; a droga era dele; não estava cobrando nada deles. Esclareceu, ademais, que R\$ 180 era de seu trabalho, sendo R\$ 60,00 dele e o restante era de seus amigos, os quais tinha dado para comprar drogas, carne e cerveja para fazer churrasco. Afirmou que consume drogas desde os 16 anos. Pontuou que teve passagem na Fundação Casa por tráfico de drogas. Disse que não possui nada contra os policiais e as demais testemunhas arroladas na denúncia. Ao final, afirmou que não é proprietário do Uno branco.

Primeiramente, em relação à alegada nulidade/ilegalidade da busca pessoal realizada pelo Policiais Militares, com o devido respeito ao entendimento contrário, tenho que não deve prosperar.

No RHC 158.580, o C. Superior Tribunal de Justiça decidiu que a fundada suspeita a

que se refere o artigo 244 do Código de Processo Penal seja descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência para a diligência.

No caso em comento, a fundada suspeita restou devidamente demonstrada pelos agentes públicos em juízo. Nesse sentido, o Policial Militar Carlos Eduardo Emiliano relatou que avistaram o réu e outros dois indivíduos, em uma praça, com características de que estavam utilizando drogas. Em reforço, o Policial Militar Vanil de Carvalho Júnior acrescentou que, na referida praça, é comum uso de entorpecentes e a prática de tráfico de drogas e que, diante da atitude suspeita, decidiram realizar a abordagem. Tanto que é a abordagem resultou na localização do tóxico.

Desse modo, vislumbra-se que essas circunstâncias – características de uso de entorpecentes, num local conhecido pelo uso e comércio de entorpecentes – denotam a existência de fundada suspeita, embasada em indícios de que o réu e as outras duas pessoas estavam na posse de drogas, autorizando, dessa forma, a busca pessoal.

Assim, a nulidade/ilegalidade na busca pessoal fica afastada.

No que se refere à alegação de que o réu, nem sua genitora, autorizou o ingresso dos agentes policiais na residência, observo que, por ocasião da ida dos policiais ao domicílio do réu, havia indícios reveladores de que o acusado estava praticando tráfico de drogas no referido local, de tal modo que o estado flagrancial afasta a inviolabilidade do domicílio.

Nesse sentido, analisando o depoimento os Policiais Militares em juízo e a confissão extrajudicial do acusado (fl. 06), denota-se que, durante a abordagem, encontraram drogas e quantia em dinheiro em poder do réu, além de mais substâncias entorpecentes num veículo. Sobre os tóxicos localizados, o acusado admitiu a propriedade e a prática do comércio ilícito de entorpecentes. Em seguida, o próprio réu informou os agentes policiais que havia mais drogas em sua residência, razão pela qual os agentes públicos para lá se dirigiram.

Logo, denota-se que o increpado, na ocasião em que os Policiais Militares ingressaram em sua residência, encontrava-se em evidente situação flagrancial, tanto é que referidos indícios se confirmaram com a localização de entorpecentes, razão pela qual os agentes públicos estavam autorizados a ingressar no local.

A cláusula constitucional da inviolabilidade domiciliar não é garantia absoluta, pois o inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal preconiza que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito”.

A Colenda Suprema Corte, em r. decisão da lavra do e. Ministro Alexandre de Moraes, no julgamento do RE 1342077/SP, reafirmou a tese fixada no julgamento do RE 603.616/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 280 de Repercussão Geral), ao assentar:

"O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante".

Na mesma r. decisão, o e. Ministro Alexandre de Moraes anulou o v. acórdão do C. STJ (HC 598.051-SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz) que exigia consentimento do

morador comprovado por documentação escrita da diligência policial e gravação audiovisual, porque tais exigências consubstanciam inovação em matéria constitucional e implantação obrigatória de medidas não previstas em lei e que são atinentes à organização administrativa e orçamentárias dos órgãos de segurança pública das unidades federativas.

Nessa mesma linha de raciocínio, já se decidiu:

“3. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial encontra-se evidenciada na associação das seguintes circunstâncias narradas nos autos: I) tratar-se de acusado foragido da justiça em outra ação penal também por delito de tráfico de drogas e previamente reconhecido; II) policiais já estavam em diligência para apurar informações recebidas sobre a comercialização de entorpecentes pelo paciente utilizando determinado veículo; e III) fuga do acusado para dentro de casa após a abordagem policial, tentando escapar pela parte de trás da residência, sendo preso neste momento diante do certo realizado pelos policiais que, após, encontraram mais de 9kg de cocaína na residência.” (STJ, AgRg no HC 615563/SC, Min. Ribeiro Dantas, DJe 08/02/2021).

Ao propósito, não se pode olvidar do entendimento jurisprudencial no sentido de que, em caso de crimes permanentes, prescindível mandado de busca e apreensão em razão da situação de flagrante:

HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas e Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido com Numeração Suprimida – Preliminarmente, pleiteia o reconhecimento da ilicitude da prova decorrente do cumprimento de mandado de busca e apreensão pelos policiais que diligenciaram em endereço diverso do explicitado na ordem judicial, sem fundadas razões para tanto – NÃO VERIFICADO – Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de drogas e da posse ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida, configurando exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da CF. (...) (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2138462-39.2019.8.26.0000; Relator(a): Des. Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Bárbara d'Oeste - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/08/2019; Data de Registro: 07/08/2019).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONCURSO DE PESSOAS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA. CRIME CONTINUADO. DISPENSABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO (...) III - É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se tratar de flagrante de crime permanente, como no caso de tráfico de drogas, sendo possível a realização das medidas necessárias, não havendo falar em ilicitude das provas obtidas. (Precedente) (HC 309.554/BA, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 05/03/2015, DJe 27/03/2015).

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LEGALIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO AO ART. 214 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 2. Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio

alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 3. O crime de tráfico de drogas na modalidade atribuída ao ora recorrente (guardar ou ter em depósito) possui natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial (...). (AgRg no AREsp 1786034/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021).

Logo, com a devida vênia à tese defensiva, não reconheço a nulidade/ilicitude em apreço.

No mérito, diante do contexto fático-probatório, tem-se o seguinte cenário: a) Policiais Militares realizavam patrulhamento, quando avistaram o réu e mais duas pessoas, aparentando estar usando entorpecentes, em uma praça, conhecida pelo consumo e tráfico de drogas; b) ao lado do réu e das duas pessoas, os Policiais visualizaram um veículo Fiat Uno branco, sobre o qual havia denúncia, no sentido de que era utilizado para levar drogas a Itobi; c) diante dessas circunstâncias, os Policiais realizaram abordagem, localizando em poder do réu uma porção de cocaína, de maconha e a quantia de R\$ 190,00; d) o acusado admitiu a propriedade dos entorpecentes e a prática do comércio ilícito de drogas, além de dizer que estava aguardando a chegada de uma pessoa, a qual iria buscar tóxicos no local; e) no mencionado veículo, foram encontradas mais cocaína e maconha; f) ato contínuo, o réu contou aos Policiais que, em sua residência, havia mais drogas; g) na residência, foram encontradas mais três porções de maconha, ainda não fracionadas; uma porção de cocaína a granel; alguns pinos de cocaína; e uma balança de precisão; h) o réu, em seus esclarecimento prestado em solo policial, confessou os fatos (fl. 6).

Tais circunstâncias, analisadas em conjunto e sopesadas entre si, não deixam dúvidas acerca da ocorrência da narcotraficância, sendo certo que, realmente, as substâncias entorpecentes localizadas se destinavam ao comércio ilícito.

Ademais, diante desses elementos, a negativa do acusado restou isolada e descompassada das demais provas dos autos.

Ao propósito, em que pese o acusado alegar que estava no local dos fatos aguardando sua companheira e que a balança de precisão pertencia a ela, nada nesse sentido foi comprovado, não tendo o réu sequer arrolado referida testemunha para confirmar essa versão.

Desse modo não remanescem dúvidas de que os entorpecentes apreendidos pertenciam ao réu e seriam por ele comercializados, merecendo prevalecer os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público na fase inquisitorial e em Juízo, que narraram os fatos com riqueza de detalhes e afirmaram de forma coerente e uníssona.

De mais a mais, ainda que o réu tenha alegado uma suposta agressão perpetrada por um dos Policiais Militares e a ausência de autorização para ingressar em sua residência, não há nenhum motivo concreto para falsa incriminação apresentado e os policiais, ao prestarem depoimento em juízo, além de firmes e coerentes, fizeram relatos verossímeis, nada existindo que possa infirmar a lisura de suas palavras.

Sobre o testemunho dos policiais, confira-se:

“Os testemunhos de policiais, destacados para a realização da repressão criminal,

devem ser aceitos quando se prestam a dar contas da tarefa realizada, inexistindo motivo para que sejam considerados tendenciosos. Podem ser rechaçados somente quando comprovado que houve falseamento da verdade ou que estão em desconformidade com o restante da prova, como ocorre com todo tipo de prova. Nesse teor, também, o v. aresto do STF no HC nº 73.518/SP, rel. MIN. CELSO DE MELLO" (TACRIM, Apelação nº 1327851/4, 12ª Câmara, Rel. Des. LUÍS GANZERLA, j. 7-4-2003, v.u.).

No mesmo sentido, de acordo com reiterada jurisprudência, "não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ, AC, Rel. Des. SYNÉSIO DE AQUINO, RDTJRJ 7/287).

Acrescente-se que, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

É dizer, para a configuração do delito do art. 33 da Lei 11.343/06, crime de ação múltipla ou de conteúdo variável, é suficiente que o agente incida em apenas uma das condutas nucleares – trazer, guardar, ter em depósito, etc. – pois a consumação não exige qualquer outro resultado, como a venda ou a efetiva entrega da coisa, bastando a posse da droga.

Nesse sentido, têm-se exemplo da jurisprudência:

"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes dos agentes" (RT 584/347, Rel. Desembargador GERALDO GOMES).

De fato, as assertivas dos policiais, no tocante ao fato principal, mostraram-se harmônicas, firmes e condizentes com todos os elementos sensíveis da infração e subsídios de convicção coligidos aos autos. Não foram abaladas por nenhum fator concreto e, bem por isso, devem ser prestigiadas.

As versões defensivas, por seu turno, não merecem, com a devida vênia, valor probatório superior ao dos servidores públicos, que não tinham relação de afeto ou ódio com o acusado e estavam comprometidos com a cabal apuração dos fatos e com a defesa do interesse da sociedade.

Não há nos autos motivo algum para imaginar que os testigos inculpatórios tenham sido fruto da ação de pessoas que agiram de forma leviana tão só para prejudicar o acusado gratuitamente.

Não há que se falar em insuficiência probatória, já que as provas são suficientes à condenação, sendo de rigor a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas.

Ao propósito, em que pese o acusado ter se retratado da sua confissão realizada em solo policial, ressalte-se que a confissão extrajudicial, mesmo posteriormente retratada em juízo, possui valor probante quando apreciada em conjunto e estando de acordo com as demais provas, porquanto a confissão é válida pelo seu conteúdo em si e pela consonância com os demais elementos de convicção, e não pelo local onde é feita.

A circunstância de a confissão ter sido feita em solo policial, em procedimento de natureza inquisitória, em que inexistente contraditório, não lhe retira o valor,

mormente porque não infirmados pelos demais elementos de prova constantes nos autos.

Em seu interrogatório judicial, o réu retratou-se de sua confissão em solo policial. Todavia, irrelevante a retratação posterior, já que a validade da confissão não está atrelada ao local em que prestada, mesmo porque não há elementos seguros de que o acusado tenha sofrido qualquer forma de coação na fase extrajudicial para que admitisse o evento delituoso que lhe é imputado.

Nesse contexto, válida a confissão policial:

"PROVA - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - RETRATAÇÃO JUDICIAL DISTANCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO - PREVALECIMENTO DA PRIMEIRA. A confissão extrajudicial prevalece sobre a retratação judicial, se esta se acha em desarmonia com o conjunto probatório. A jurisprudência é uníssona, quando dá maior credibilidade à confissão extrajudicial do que à retratação em Juízo, desde que a primeira esteja amoldada às demais provas e circunstâncias dos autos, e a segunda, totalmente inverossímil e distanciada do conjunto probatório" (TJMG, 2.^a C.Crim., Ap. 1.0079.01.009163-9/001, Rel. Desembargador HYPARCO IMMESI, v.u., j. 25.01.2007; pub. DOM de 03.04.2007).

"A simples retratação em Juízo sem ressonância nos autos não invalida confissão feita perante a autoridade policial" (TJMG - AP - Rel. GUIMARÃES MENDONÇA - RT 666/333).

"Se o réu, depois de haver confessado a autoria do crime, se retrata em Juízo, assume o ônus de provar sua alegação, sob pena de, não o fazendo, sua negativa se tornar um alibi não comprovado" (TAMG, 2.^a C. Crim., Ap. 279194-8, Rel.^a Juíza MÁRCIA MILANEZ, v.u., j. 03.08.1999; DOMG de 02.02.2000).

"PENAL - FURTO QUALIFICADO - ART. 155, § 4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - RETRATAÇÃO EM JUÍZO - NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA - Condenação amparada em fortes indícios da autoria. Prova. Sentença. Fundamentação. Substituição da pena. Requisitos do art. 44 não preenchidos. Não há como prosperar a retratação em juízo quando o contexto no qual se insere torna patente a veracidade das declarações prestadas extrajudicialmente. Do mesmo modo, as confissões produzidas na fase policial são hábeis a embasar um Decreto condenatório, porque corroboradas por outros elementos de prova. O prolator da sentença não está obrigado a referir-se, minuciosamente, a cada uma das circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, sendo suficiente apenas que a decisão seja fundamentada. Negado provimento aos recursos." (TJDF - APR 20020710177385 - 1ª T.Crim. - Rel. Des. MARIO MACHADO - DJU 15.06.2005 - p. 42).

A retratação judicial do réu restou isolada nos autos, ao contrário de sua confissão extrajudicial que foi corroborada pelos depoimentos dos policiais ouvidos em Juízo sob o crivo do contraditório.

De outra parte, em que pese a alegação de que as drogas eram destinadas ao seu consumo próprio, nada se comprovou a esse respeito. A propósito, a partir das circunstâncias acima indicadas, nota-se que referida tese defensiva restou isolada das demais provas produzidas nos autos.

Logo, a alegação de ser mero usuário, o que, repiso, não foi comprovado nos autos, cai por terra diante da fragilidade das alegações defensivas.

Cediço que, "Nenhuma incompatibilidade existe entre o tráfico de entorpecente e o vício. Ao contrário. Em regra, vivem associados" (RT 411/104, Rel. Desembargador HUMBERTO DA NOVA).

Do mesmo modo, não restou comprovado que as drogas apreendidas destinavam ao

oferecimento, eventual e sem objetivo de lucro, a pessoa de relacionamento do acusado, para juntos a consumirem, mas sim que se destinavam ao comércio espúrio.

Em suma, comprovadas materialidade e autoria do delito descrito na denúncia, e elidida a versão exculpatória, a condenação do acusado é medida de rigor.

Apurada a responsabilidade penal, passo à dosimetria da pena, segundo o critério previsto no art. 42 da Lei de Drogas e nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, observo que o acusado não ostenta condenações definitivas, devendo ser considerado primário e sem antecedentes criminais (fls. 25). Todavia, quando menor, teve passagem pela Fundação Casa (fls. 26), como ele próprio admitiu quando ouvido em juízo. Como já decidiu o STJ, "os atos infracionais pretéritos, a despeito de inservíveis para a configuração de reincidência e/ou maus antecedentes, podem ser valorados para aferição da personalidade voltada à prática de ilícitos, o que justificaria a segregação cautelar em virtude do fundado receio de reiteração delitiva (RHC n. 63.855/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Rel. p/ Acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/5/2016, DJe de 13/6/2016)" (STJ, 5ª T., HC 362.691/SP). Assim, impõe-se a majoração da pena-base em 1/6.

Na segunda fase, incidente a atenuante da menoridade relativa e da confissão, razão pela qual retomo à pena ao patamar mínimo.

Na terceira fase não restou configurada a causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06. O redutor em comento é destinado ao tráfico episódico, ocasional, eventual ou isolado. Não é o caso dos autos. A congêrie probatória evidencia, à saciedade, que o réu se dedicava a atividades criminosas, haja vista a quantidade e a variedade dos entorpecentes, bem como o instrumento apreendido (balança de precisão) utilizado na prática do comércio ilícito de drogas. Ademais, mencione-se que, em solo policial, o réu admitiu que estava traficando há duas semanas e tinha ido a Porto Ferreira buscar substâncias entorpecentes. Logo, não pode ser beneficiado com a causa de diminuição de pena. Em situação semelhante, já decidiu, mutatis mutandis, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PACIENTE CONDENADO À PENA CORPORAL DE 5 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE DEDICA-SE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

INVIABILIDADE. MONTANTE DA PENA QUE NÃO ATENDE AO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO INCISO I DO ART. 44 DO CP. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...] - Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

- Esta Corte Superior tem decidido que a quantidade, a variedade e a nocividade da droga, bem como as circunstâncias nas quais foi apreendida, são elementos que evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa e, em decorrência, podem embasar o não reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n.11.343/2006. Precedentes.

- Hipótese em que o Tribunal de origem conferiu legalidade à manutenção do não reconhecimento do privilégio, ao fundamentar que a quantidade, a variedade e a nocividade dos entorpecentes apreendidos (15,13 gramas de cocaína e 26,23 gramas de crack), aliadas às circunstâncias em que o delito ocorreu, permitem concluir que o

acusado dedica-se a atividade criminosas. Modificar tal conclusão requer o revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes.

- Mantida a condenação em patamar superior a 4 anos, resulta inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do CP.

- Habeas corpus não conhecido." (HC 362.266/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 23/09/2016).

Assim sendo, fixo a pena definitiva em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

O valor unitário da sanção pecuniária cumulativa, ante as condições financeiras do acusado, é fixado no mínimo de 1/30 do salário mínimo nacional, vigente na data do fato, atualizado desde então.

A despeito da primariedade do agente, é preciso ter em mente as circunstâncias judiciais desfavoráveis utilizadas na primeira fase e os elementos mencionados na terceira fase. Ressalte-se, ainda, que o delito é apenado com reclusão (CPP, art. 313, I), além do seu caráter hediondo, a justificar modalidade mais severa e maior rigor penitenciário para início de desconto da segregativa. Além disso, o réu ostenta circunstância judicial negativa e restou comprovado seu envolvimento não casual no tráfico de entorpecentes. Por essas razões, fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena, por ser o único condizente com o princípio da suficiência dada a gravidade do delito, que perturba a ordem social, alicia e corrompe crianças e adolescentes, aniquila a força produtiva de usuários e viciados e fomenta a criminalidade, produzindo efeitos deletérios a toda coletividade, a exigir tratamento mais rigoroso sob pena de a reprimenda não alcançar, a contento, sua finalidade preventiva e retributiva.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 12.736/2012, porque o regime inicial não foi fixado com base na quantidade de pena aplicada.

Pelas mesmas razões, desaconselhável, no caso específico dos autos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal) ou ainda a concessão de sursis (art. 77 do Código Penal).

As demais alegações não comportam outras considerações ou digressões, por haver incompatibilidade lógica com o quanto já mencionado.

Como é sabido, o órgão julgador não está obrigado a responder todas as alegações ou se referir, um a um, a todos os seus argumentos. Com efeito, "o que a Constituição exige é que o juiz ou tribunal dê as razões do seu convencimento, não estando ele obrigado a responder a todas as alegações dos réus, mas tão-somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão" (STF, HC nº 82.746-SP). Ainda nesse sentido, "Não se tem como omissa a sentença condenatória que, embora não se referindo, expressamente, à tese da defesa, fundamenta a condenação com base nos elementos probatórios reputados válidos para caracterizar o crime narrado na denúncia e sua autoria. (...). Embora seja necessário que o Magistrado aprecie todas as teses ventiladas pela defesa, torna-se despiciendo a menção expressa a cada uma das alegações se, pela própria decisão condenatória, resta claro que o julgador adotou posicionamento contrário" (STJ, RHC nº 12.842-0/PR).

Assim, a soma de alegações choca-se contra os fatos verificados nos autos, e conseqüentemente, são afastados os argumentos restantes, por inaplicáveis.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para condenar o réu FRANCISCO PEDRO BARBOSA FILHO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao

pagamento de 500 dias-multa, estes arbitrados unitariamente no mínimo legal.

Custas na forma da lei (artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea “a” da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003).

O acusado não poderá apelar em liberdade, visto que subsistem os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar. A prova produzida sob os auspícios do contraditório corrobora a manutenção da prisão cautelar decretada quando de sua prisão em flagrante. Não se verifica alteração do quadro que motivou a segregação preventiva. Ainda estão presentes circunstâncias de fato e de direito necessárias para manutenção da prisão. As circunstâncias e o cenário fático que ensejaram a decretação da prisão preventiva restaram confirmados no curso da instrução e, portanto, os motivos que ensejaram a custódia cautelar permanecem intactos e incólumes. Ademais, na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art.312 do Código de Processo Penal” (AgRg no RHC 116.112/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T. STJ, DJe 10/12/2019). Negado ao réu o direito de recorrer em liberdade, recomende-se-os na prisão em que se encontra. Expeça-se ofício recomendatório.

No tocante à destruição da droga apreendida reporto-me à decisão proferida às fls. 34.

Nos termos do artigo 91, II, “b”, do Código Penal e do artigo 63 e seguintes da Lei 11.343/06, decreto o perdimento do valor e do veículo automotor apreendidos em favor da União, pois as circunstâncias que envolvem os fatos indicam que a quantia é fruto do comércio ilícito de substâncias entorpecentes, não tendo sido demonstrada a origem lícita do dinheiro, ônus que lhe competia, bem como que o veículo era usado na prática do delito em questão, uma vez que a droga foi encontrada em seu interior.

Em relação aos aparelhos celulares apreendidos, considerando que não há elementos indicativos de que eram utilizados para a prática tráfico de drogas, autorizo sua restituição. Expeça-se o necessário.

Transitada em julgado esta sentença: a) expeça-se guia de recolhimento definitiva; b) notifique-se o réu para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias (art. 50, caput, do CP); c) oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD); d) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da CF.

P.I.C. Dispensado o registro (Provimento CG nº 27/2016).

Casa Branca, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA